

CUESTIÓN

Dolores cedió a su hija Araceli un piso de forma gratuita con la condición de que se lo restituyese en caso de necesidad. Al cabo de cinco años, Dolores necesita el piso y se lo reclama a su hija, la cual se niega a irse del mismo. ¿Qué opciones tiene Dolores?

- a) Plantear una demanda de juicio verbal para la recuperación de la finca cedida en precario.
- b) Plantear una demanda de juicio ordinario para el desahucio del piso por incumplimiento por parte de Araceli de las condiciones.
- c) Dolores no tiene ninguna opción ya que cedió el piso a su hija sin contrato y de forma gratuita.
- d) Podrá plantear una acción de retracto a través de una demanda de juicio ordinario.

RESPUESTA CORRECTA: A

2. REPRESENTACIÓN EN EL NEGOCIO JURÍDICO. REPRESENTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA Y LEGAL. EL PODER

La representación voluntaria como modalidad de representación en la personalidad civil: representación directa e indirecta

1410

Dentro de la representación voluntaria es donde cobra relevancia la distinción entre la representación directa (en la que el representante actuará por cuenta y en nombre del representado) y la representación indirecta (en la que el representante actuará por cuenta del representado, pero bajo su nombre, y no bajo el de su representado).

La **representación directa** es aquel tipo de representación en la cual el representante va a actuar por cuenta y en nombre de otro sujeto, que será, en consecuencia, su representado. Esta situación debe ser completamente conocida para las personas que van a realizar algún negocio jurídico con el nombrado como representante.

- La **existencia de la *contemplatio domini***, esto es, el conocimiento que tienen las partes, en las actuaciones en nombre ajeno, de la existencia de un *dominus* detrás del representante, por lo que se puede decir que a través de este (o de la autorización que ostente) se puede producir la «contemplación del dueño».
- El **otorgamiento de un poder (apoderamiento)** que faculta al representante, mediante un título de legitimación, a llevar a cabo negocios por cuenta de otra persona (representado) y recoge los límites a la hora de ejecutar o concertar determinados negocios jurídicos.

Entendiendo el acto de **apoderamiento** como un negocio con trascendencia jurídica, las características que lo particularizan son las siguientes:

1. Se trata de un **negocio unilateral**, puesto que su otorgamiento deriva de una declaración de voluntad del representado, no siendo necesaria declaración de voluntad por la parte que habrá de actuar como representante.
2. Se trata de un **negocio recepticio**, puesto que dicha declaración de voluntad debe ser conocida por las partes para que la misma se considere válida; en caso contrario, el **apoderamiento** devendría ineficaz y no producirá efecto alguno.

3. Se trata de un **negocio independiente y abstracto** ya que el mismo se considera un negocio jurídico independiente de lo que se conoce como relación subyacente, aquella en la que se suele recoger el negocio de gestión por el que el representante se ve obligado a actuar.

En cuanto a las **formalidades** exigidas para llevar a cabo el otorgamiento de poder, es preciso destacar que no hay una regulación específica al respecto, por lo que será de aplicación lo regulado en el artículo 1710 del Código Civil, relacionado con las formas de celebración del contrato de mandato. Teniendo en cuenta lo allí establecido, **se considera que el otorgamiento de poder podrá hacerse de forma expresa o tácita**. En el supuesto de **realización de forma expresa**, este podrá otorgarse mediante documento público o privado, o en su caso, de palabra. **Cuando el otorgamiento de poder sea tácito**, es preciso prever los medios que faciliten a los terceros el conocimiento de esta situación.

En lo relativo a los **aspectos que caracterizan al poder** que se le otorga al representante, se considera que, en caso de ser concedido en términos generales, este no recoge los actos en concreto que el representante puede llevar a cabo y, por tanto, siguiendo con lo establecido por el artículo 1713 del Código Civil, el representante solo podrá realizar actos de administración. En caso de que se haya concedido de forma expresa, será en el propio poder donde se establezcan aquellas actuaciones para las cuales se va a poder llevar a cabo la representación.

En cuanto al objeto del apoderamiento hay que hacer referencia a que este puede ser:

1. **General**: cuando la representación comprende todos los negocios del poderdante.
2. **Especial**: cuando la representación queda restringida a determinados negocios y no a todos.

En lo relativo a la **extensión del poder**, se debe tener en cuenta que el representante tiene que ajustarse a los límites establecidos en el mismo.

Además, el poder **puede contener límites determinados**, como por ejemplo la obligación de actuar siguiendo las instrucciones dadas por el representado o incluso la prohibición de realizar determinados actos con transcendencia jurídica. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo establecido por el artículo 1715 del Código Civil, donde se determina que no se considerarán sobrepasados los límites marcados en la actuación del representante, siempre y cuando de dicha actuación se produzca un beneficio para el representado.

La **invalidéz del apoderamiento** va a producirse siempre y **cundo concurren las causas de invalidez de los negocios jurídicos**. La causa de invalidez más común se produce ante la presencia de algún tipo de vicio de la voluntad. Es de destacar el hecho de que el representante debe siempre actuar conforme al interés de su representado, pues en caso contrario, podría incurrir en abuso de poder, lo que hace aparecer una causa justa para que el otorgamiento se revoque y pueda impugnarse el negocio de que se trate.

La **extinción del poder** encuentra su regulación en los artículos 1732 a 1739 del Código Civil, que contemplan como causas de extinción las siguientes:

1. Revocación por parte del representado.
2. Renuncia del mandatario. Se alude a la declaración de voluntad por parte del representante, para dar a conocer al representado el fin de la representación.
3. Por muerte o por concurso del mandante o mandatario.

4. Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas de apoyo que incidan en el acto en que deba intervenir en esa condición.
5. Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en este código respecto de los mandatos preventivos.

La **representación indirecta** (entendida como aquella representación voluntaria caracterizada por el hecho de que el representante actúa por cuenta del representado, pero no en su nombre, sino en nombre propio) sí se puede acudir, a título de ejemplo, a lo contenido en el artículo 1717 del Código Civil, en lo concerniente a las relaciones del contrato de mandato, y al artículo 246 del Código de Comercio, respecto a la figura del comisionista.

Es decir, en este caso, el mandatario (representante) es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuese personal suyo. Se exceptúa el caso de que se trate de cosas propias del mandante (representado). Todo lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las acciones que se puedan entablar entre mandante (representado) y mandatario (representante).

Contrato de mandato

1420

➤ Concepto del contrato de mandato

El contrato de mandato viene regulado en los artículos 1709 a 1739 del Código Civil. Su definición viene dada en el artículo 1709 del Código Civil:

«Por el contrato de mandato **se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra**».

Los sujetos del contrato de mandato son:

1. **El mandante:** el que encarga el servicio o actividad.
2. **El mandatario:** el que realiza la actuación determinada por cuenta y en interés del anterior.

El mandante deberá tener capacidad general para contratar y capacidad para el acto concreto a realizar. Sin embargo, respecto del mandatario, solo se requiere capacidad general para contratar, tal y como lo establece el artículo 1716 del Código Civil: «El menor emancipado puede ser mandatario, pero el mandante solo tendrá acción contra él en conformidad a lo dispuesto respecto a las obligaciones de los menores» (el menor emancipado puede ser mandatario, aunque solo responderá en la medida en que se haya enriquecido).

➤ Características del contrato de mandato

El mandato tiene las siguientes características:

- Puede ser constituido de modo **expreso o tácito como también la aceptación**, la cual, si es tácita será deducida de los actos del mandatario (art. 1710 del Código Civil).
- Se supone **gratuito**, salvo pacto en contrario (art. 1711 del Código Civil).

- Puede ser **general** (comprende todos los negocios del mandante) o **especial** (comprende negocios determinados del mandante) (art. 1712 del Código Civil).
- Generalmente **comprende únicamente los actos de administración**. Para que suponga cualquier otro acto se requiere de mandato expreso (transigir, enajenar, hipotecar, o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio) (art. 1713 del Código Civil).

➤ **Obligaciones del mandatario**

En el Código Civil, se recogen las siguientes obligaciones:

- En el artículo 1718 del Código Civil se establece la obligación de **responder de los daños y perjuicios que de no ejecutar la acción objeto del mandato se le ocasionen al mandante**.
- Del artículo 1719 del Código Civil, se extrae la obligación de que **el mandante debe ejecutar conforme a las instrucciones del mandatario, en su defecto, procederá conforme a la naturaleza del negocio jurídico**. Recalcando lo anterior, el artículo 1714 del Código Civil establece la regla de que el mandatario, **no puede traspasar los límites del mandato**; y en el artículo 1715 del Código Civil que **no se consideran traspasados los límites del mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante que la señalada por este**.
- **Obligación de rendir cuentas**, establecida en los artículos 1720 y 1724 del Código Civil; que establecen que el mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y abonar lo que hubiese percibido en virtud del mandato y también, que debe intereses de las cantidades que aplicó a usos propios, incluso las que quede debiendo una vez finalizado el mandato y esté constituido en mora.
- **Responsabilidad frente al mandante por incumplir sus obligaciones**, así lo dice el artículo 1718 del Código Civil: «(...) y responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasione al mandante»; y el artículo 1726 del Código Civil: «El mandatario es responsable, no solamente del dolo, sino también de la culpa, que deberá estimarse con más o menos rigor por los Tribunales, según que el mandato haya sido o no retribuido».

➤ **Sustitución del mandatario**

Artículo 1721 del Código Civil

«El mandatario puede nombrar sustituto si el mandante no se lo ha prohibido; pero responde de la gestión del sustituto:

- 1.º Cuando no se le dio facultad para nombrarlo.
- 2.º Cuando se le dio esta facultad, pero sin designar la persona, y el nombrado era notoriamente incapaz o insolvente.

Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición del mandante será nulo».

Artículo 1722 del Código Civil

«En los casos comprendidos en los dos números del artículo anterior puede además el mandante **dirigir su acción contra el sustituto**».

CUESTIÓN

Soraya firma un contrato de mandato con Lucía a cambio de una remuneración. En el contrato, Soraya es la mandante y Lucía la mandataria, y no se contempla nada acerca de si Lucía puede nombrar un sustituto/a para llevar a cabo el mandato. Lucía decide encomendar el encargo a su compañera Laura. Señala la respuesta correcta:

- a) Solo cabrá la sustitución si Soraya lo hubiera autorizado expresamente en el contrato.
- b) La sustitución en el contrato de mandato no es posible en ningún caso.
- c) Lucía puede nombrar sustituta a su compañera Laura, pero Lucía responderá frente a Soraya de la gestión de Laura.
- d) Lucía en este caso no puede nombrar sustituta ya que se trata de un contrato de mandato oneroso y solo es posible la sustitución en los contratos de mandato gratuitos.

RESPUESTA CORRECTA: C

➤ **Responsabilidad de dos o más mandatarios**

Artículo 1723 del Código Civil

«La responsabilidad de dos o más mandatarios, aunque hayan sido instituidos simultáneamente, no es solidaria, si no se ha expresado así».

CUESTIÓN

En un contrato de mandato se designaron simultáneamente a dos mandatarios sin especificar de qué forma responderán. Señala la respuesta correcta:

- a) Los dos responderán solidariamente.
- b) Ambos responderán de forma mancomunada.
- c) Actuará el que primero conste en la lista y en caso de imposibilidad de actuar este se designará al segundo.
- d) El nombramiento de un segundo mandatario supone la revocación tácita del otro mandatario.

RESPUESTA CORRECTA: B

➤ **Obligaciones del mandante**

El mandante tendrá las siguientes obligaciones:

- **Pagar lo debido por la retribución**, cuando se hubiere constituido un mandato oneroso.
- **Anticipar al mandatario, si este lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato**. Si el mandatario las hubiera anticipado, debe reembolsarlas el mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal de que el mandatario esté exento de culpa. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo la anticipación. El mandatario podrá retener en prenda el objeto del mandato hasta que se haga efectivo el reembolso (arts. 1728 y 1730 del Código Civil).

- **Indemnizar por los daños y perjuicios causados en el cumplimiento del mandato cuando no medie culpa ni imprudencia del mandatario** (art. 1729 del Código Civil), pudiendo el mandatario retener en prenda el objeto del mandato hasta que se haga efectiva la indemnización.
- **Si se constituye el contrato de mandato por dos mandantes, estos quedan obligados solidariamente** (art. 1731 del Código Civil).

➤ **Modos de extinción del mandato**

Artículo 1732 del Código Civil

«El mandato se acaba:

- 1.º Por su revocación.
- 2.º Por renuncia del mandatario.
- 3.º Por muerte o por concurso del mandante o del mandatario.
- 4.º Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas de apoyo que incidan en el acto en que deba intervenir en esa condición.
- 5.º Por la constitución en favor del mandante de la curatela representativa como medida de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, a salvo lo dispuesto en este Código respecto de los mandatos preventivos».

El mandante puede revocar el mandato, y obligar al mandatario a devolver el documento en el que conste el mandato. Si el objeto del mandato hubiera sido contratar con determinadas personas, la revocación no puede perjudicarles si no se les avisa de la misma.

El artículo 1735 del Código Civil establece que «el nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio produce la revocación del mandato anterior desde el día en que se hizo saber al que lo había recibido, salvo lo dispuesto en el artículo que precede».

El mandatario podrá renunciar al mandato, para ello deberá ponerlo en conocimiento del mandante. En caso de que este sufre perjuicios por esa renuncia, el mandatario le deberá indemnizar, salvo que su renuncia se funde en la imposibilidad de continuar con el mandato sin grave detrimento suyo. Sin embargo, aunque el mandatario haya renunciado con justa causa al mandato, deberá continuar su gestión hasta que el mandante tome las disposiciones necesarias para suplir esta falta.

Para el caso de muerte del mandatario, los artículos 1738 y 1739 del Código Civil, establecen lo siguiente:

Artículo 1738 del Código Civil

«Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe».

Artículo 1739 del Código Civil

«En el caso de morir el mandatario, deberán sus herederos ponerlo en conocimiento del mandante y proveer entretanto a lo que las circunstancias exijan en interés de este».

La representación legal como modalidad de representación en la personalidad civil

El artículo 1259 del Código Civil establece que nadie («ninguno») puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por este o sin que tenga, por la ley, su representación legal, añadiendo a continuación que «el contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante».

Los distintos supuestos en los cuales va a tener cabida la representación legal aparecen recogidos no solo en el Código Civil, sino también en diversa legislación específica, y se refieren sobre todo a los ámbitos del derecho de la persona y el derecho de familia.

Dentro de los **supuestos más relevantes de representación legal** estarían los siguientes:

- El **caso del titular de la patria potestad**, o del defensor judicial, en relación a los hijos e hijas que estén bajo la misma: este aparece regulado en los artículos 154, 162 y 163 del Código Civil.
- El caso de la **tutela, defensor judicial, curatela**, etc. (Nuevos títulos IX y XI del libro I del CC).
- El caso del **representante del ausente**, regulado en el artículo 184 del Código Civil.
- El del **defensor del desaparecido**, englobado en el artículo 181 del Código Civil.
- El del **representante del concebido y no nacido**, previsto en el artículo 627 del Código Civil.
- El del **administrador de la herencia**, que se encuentra regulado en los artículos 801 a 804 del Código Civil y el artículo 798 de la LEC.

Es preciso destacar el hecho de que la representación legal existe, bien para suplir la falta de capacidad de una persona a la hora de desarrollar determinados negocios jurídicos, bien para proteger determinados bienes que necesitan un tipo de protección que su titular (presente o futuro) no es capaz de asumir por sí mismo.

En cuanto a las características de la representación legal, las mismas pueden extraerse de las siguientes notas:

- Los casos de la representación legal son aquellos que son **exigidos legalmente**.
- La representación legal **se prevé ante una situación en la que una persona no puede realizar una determinada actuación por sí misma**, dado que no ostenta la capacidad requerida para llevarlo a cabo.
- Es relevante destacar el hecho de que, en algunas situaciones, **el representante ve restringida su posibilidad de actuación por la autoridad judicial**, que ejerce un control respecto de algunos negocios jurídicos que este puede realizar tanto en lo que respecta a los bienes como a la propia persona del representado.
- Pueden darse situaciones en las que **existan y se prevea la existencia de varios representantes**.
- El ámbito de la representación y **las facultades que el representante va a ostentar, dependerán del tipo de representación legal de que se trate**, y de las circunstancias particulares de cada caso concreto.
- **El representante legal no necesita de una justificación determinada para llevar a cabo un determinado negocio jurídico**, pudiendo alegar en todo caso la facultad que la ley le otorga para ello.

El poder notarial

El poder notarial es un documento de carácter público (se otorga ante notario) por el que el poderdante autoriza a una persona a realizar determinada actividad en el tráfico jurídico.

El poder puede ser general o especial.

➤ Poder general para pleitos (art. 25 de la LEC)

Este poder facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos.

El poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada expresa e inequívocamente.

Los procuradores que ostenten la representación procesal de un litigante beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita podrán realizar válidamente, en nombre de su representado, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la tramitación de aquellos.

A TENER EN CUENTA. La LO 1/2025, de 2 de enero, con entrada en vigor el 3 de abril de 2025, modifica el art. 25 de la LEC.

➤ Poder especial para pleitos (art. 25 de la LEC)

Será necesario poder especial:

1. Para la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las manifestaciones que puedan comportar sobreseimiento del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto.
2. Para ejercitar las facultades que el poderdante hubiera excluido del poder general, conforme a lo dispuesto en el punto anterior.
3. En todos los demás casos en que así lo exijan las leyes.

CUESTIONES

1. Alejandro, procurador de los tribunales, comparece en nombre del demandando en la audiencia previa con un poder general para pleitos. El demandado pretende allanarse parcialmente. Alejandro acude a la audiencia previa acompañado de la abogada del demandado, pero sin el demandado. Señala la respuesta correcta:

- a) El poder general para pleitos otorgado es suficiente, Alejandro no precisa poder especial para allanarse.
- b) Para allanarse no es necesario otorgar poder general ni especial para pleitos.
- c) Al no haber comparecido personalmente el demandado y no haber otorgado poder especial para pleitos a Alejandro para allanarse, se le tendrá por no comparecido en la audiencia.
- d) Alejandro será sancionado por el colegio por no comparecer con el correspondiente poder especial para pleitos.

RESPUESTA CORRECTA: C